

1500093-07.2021.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500093-07.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-07.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2023692/2021 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 15888191 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 120/21/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2023692 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 120/21/925 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS AUGUSTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de VINICIUS AUGUSTO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no caput do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública), do Código Penal.

Segundo a denúncia (fl. 1-3):

No dia 26 de janeiro de 2021, por volta de 16h00min, em ocasião de calamidade pública (Covid-19), na Avenida Rafarde, nº. 71, São Joaquim, nesta cidade e comarca, VINICIUS AUGUSTO DA SILVA, qualificado a fls. 10, guardava, para fins de

comercialização, 66 eppendorfs contendo cocaína, com peso aproximado de 50 gramas, 02 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 355 gramas, 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 65 gramas, e 25 (vinte e cinco) frascos contendo líquido conhecido como “lança-perfume” (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, auto de constatação de fls. 08/09 e laudos de exame químico toxicológico de fls. 78/80 e 81/84), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 120) citado (fl. 150) e apresentou defesa prévia (fl. 107), sendo designada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Foi realizada perícia para atestar a dependência do réu (autos 0001789-55.2021.8.26.0533), que concluiu pela sua imputabilidade.

Ao fim, o Ministério Público pediu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Em relação à dosimetria pediu a majoração da pena base em virtude de ter sido apreendida cocaína com o réu, o reconhecimento da reincidência e, afastamento do privilégio e fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, em alegações finais escritas (fls. 257-265) pleiteou sua absolvição pela falta de provas suficientes para condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Assim dispõe o artigo 33 da Lei n. 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da materialidade do crime e de sua autoria.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6-9), auto de exibição e apreensão (fls. 10-11), auto de constatação preliminar (fls. 12-13) e laudos periciais de fls. 85-88 que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa. Vejamos a prova oral colhida.

A testemunha Evelyn Laize do Prado, policial militar, disse em juízo que realizava patrulhamento pelo bairro São Joaquim quando um senhor os parou e informou que um indivíduo de vulgo Boquinha estava guardando drogas em uma casa na avenida Raffard, e que na frente dessa residência era realizado o fracionamento da droga no período noturno. Quando chegaram no local já viram o indivíduo que tentou fugir e foi abordado. Com ele foi encontrado o valor de 50 reais, indagado, disse que tinha apenas uma pequena quantidade para uso no interior da sua casa em um pote. Durante a diligência já viram 2 frascos de lança perfume na janela. Com autorização do morador entraram na residência e encontraram o pote de maconha que ele havia dito. Porém os policiais ainda sentiam o cheiro de maconha e solicitaram apoio ao canil, e a cadela localizou 66 eppendorfs e uma balança, além de 23 frascos de lança perfume e, no vão da janela, 22 porções de maconha e outras 2 maiores. Questionado novamente ele contou que havia trancado o barracão da frente, onde a cadela encontrou outros dois pedaços grandes de maconha. Ele disse que estava guardando as drogas pois tinha dívida para pagar. Não conhecia o réu. Ele estava sozinho no local quando foi abordado. O que justificou a abordagem foi a denúncia, na qual foram passadas as características do indivíduo, e isso, somado ao nervosismo do

réu, levou a abordagem. De fora da casa já viram os dois frascos de lança perfume, e questionado se ele usava ele disse que usava maconha e relatou que havia maconha no interior da casa para uso próprio. A delação informava que ele chamava Vinicius e o vulgo era Boquinha. Na busca pessoal foi encontrado os 50 reais. O denunciante não quis se identificar, a denúncia era só que ele guardava droga. O barraco era bem velho, de madeira, tinha bastante lixo, um sofá velho. Ele não falou para quem estava guardando.

O policial Vitor Fernando Mendonça, disse que estava em patrulhamento quando foram abordados por indivíduo que informou que Vinicius, vulgo Boquinha, estava praticando tráfico de drogas e haveria um barraco utilizado para guardar entorpecentes, e ali era fracionada a droga. Foram até o local e viram o indivíduo que demonstrou nervosismo e foi abordado. Com ele foi encontrado dinheiro, e na casa dele, na janela, havia dois frascos de lança perfume. Questionado ele falou que na residência só teria uma porção de maconha para seu uso. Pedido apoio ao canil, a cadela encontrou numa estante 66 porções de cocaína, uma balança de precisão e no fundo do corredor da casa foi encontrado lança perfume, frascos iguais aos que estavam na janela. No barraco a cadela localizou as porções maiores de maconha. Ele disse que devia dinheiro e por isso guardava a droga ali, mas não falou para quem guardava.

A testemunha Rosangela disse não ter presenciado os fatos, mas conhece o réu e o considera honesto, não sabe se ele já teve problema com drogas. Sabe que ele trabalha como servente de pedreiro, fazendo bicos. Nunca viu movimento de tráfico no local e o réu não é conhecido por ser traficante.

Em seu interrogatório, o VINICIUS AUGUSTO DA SILVA disse que a acusação é falsa. Contou que os policiais o detiveram quando ele saía da casa de sua esposa, falaram que a denúncia era sobre um tal Thiago no 71, disse que único Thiago que conhecia era parente de sua esposa. Quando disse que não se chamava Thiago, os policiais pediram para procurar Thiago dentro da casa, tendo o réu permitido, e quando ele foi pegar seu documento os policiais já entraram com tudo, procuraram no quarto, sala, viram que não tinha ninguém ali. Perguntaram para ele qual a intimidade que ele tinha com Thiago e o réu disse que não o conhecia, só sabia que ele parente de sua mulher, acreditando inclusive que ele estava preso. Foram chegando várias viaturas, perguntando para ele sobre Thiago. Havia 12 buchas de maconha em sua casa, para uso próprio. Disse que usa drogas para dormir, mas no dia não tinha usado. O resto da droga não sabe de onde surgiu. Na semana anterior tinha tido discussão com outros policiais. Disse que onde mora tem três rapazes de vulgo Boquinha e queriam saber quem era o tal "Boca de Tcheca", se sabia quem era o gerente da boca, e como o réu disse que não sabia, perguntaram do barracão e o réu disse que ele era só para guardar reciclagem, sendo o fundo aberto para as pessoas jogarem reciclagem lá. Disse que os policiais falaram que como não entregou Thiago iam jogar a droga toda nele.

Assim, tem-se de um lado a versão apresentada pelo acusado, de que, em realidade, havia em sua residência apenas doze porções de maconha, e que os policiais acabaram "jogando" a droga toda nele pois ele se recusou a informar o paradeiro de Thiago, suposto traficante procurado pelos policiais, e, de outro, a versão apresentada pelos agentes estatais.

Neste sentido, é de se observar que os depoimentos dos policiais foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, que afirmaram nem mesmo conhecer.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Ademais, como se sabe, o depoimento dos policiais não possui presunção de

veracidade absoluta, porém, quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar deve ser levado em consideração. É justamente esse o caso em análise, afinal, toda a narrativa dos policiais, repetida de maneira coesa na fase inquisitorial e sob o manto do contraditório, demonstra-se crível e em conformidade com a prova material juntada aos autos. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

Ademais, é importante ainda destacar que o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas nos "verbos" ou "núcleos" do art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito" ou "guardar" a droga. Também não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercância. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam a venda. O elemento subjetivo é determinante apenas para se descartar a hipótese de porte ou guarda da droga para uso pessoal, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Segundo o §2º deste dispositivo, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". No caso concreto, a quantidade e variedade da droga não era compatível com a figura de mero usuário, a forma como a droga foi apreendida, isto é, um tijolo e outras porções menores indica que o réu estava fracionando, e a apreensão de balança indica o destino comercial da droga. Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

Quanto às alegações defensivas, há que se dizer que a abordagem do réu foi feita após os policiais receberem informações sobre o tráfico, inclusive citando nominalmente o réu. Os policiais falaram ainda que visualizaram frascos de lança perfume logo na janela do réu. Além disso, o próprio acusado confirmou que franqueou a entrada dos policiais em sua casa e no barracão, sendo que, neste segundo, nem haveria necessidade de sua concordância uma vez que ele não residia ali e não haveria que se falar na proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Além disso, ao contrário do alegado nas manifestações defensivas, foi sim apreendida balança no local (fls. 10-11).

Logo, está bem caracterizado o crime de tráfico de drogas, afinal, a prova colhida nos autos é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal

e material. A conduta foi ilícita, o réu era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (art. 68, CP).

Primeira fase da dosimetria.

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, combinado com art. 42, da Lei de Drogas, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, não sendo possível tal valoração. O réu possui maus antecedentes (3001618-28.2013.8.26.0533 - fl. 37), porém tal condenação será utilizada na segunda fase da dosimetria, configurando reincidência. O motivo do crime é inerente ao tipo em questão. As circunstâncias do crime não são especialmente graves. As consequências, embora gravosas, são inerentes ao tipo penal e, por fim, não há que se falar em comportamento da vítima ante a natureza do crime.

Sobre a quantidade e natureza da droga, observo que a cocaína, droga de maior potencial lesivo, foi apreendida em pequena quantidade, qual seja, 12,5g (laudo de fl. 85-88). Já o restante, cerca de 400g de maconha e 170ml de "lança perfume", entendo que, embora não seja insignificante, também não extrapola o habitual para este tipo de crime. Assim, não enxergo circunstância apta a majorar a pena base. Portanto, mantenho a pena no mínimo fixado pelo legislador, qual seja, 5 anos de reclusão de 500 dias-multa.

Segunda fase da dosimetria.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado já foi condenado definitivamente, também pelo crime de tráfico (3001618-28.2013.8.26.0533 - fl. 37).

Por sua vez, quanto a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, respeitado o entendimento da ilustre representante do Ministério Público, entendo que não ficou comprovada a relação entre o cometimento do crime em tela e o estado de calamidade pública vivido, isto é, o fato de vivenciarmos uma situação de calamidade pública em nada facilitou ou influenciou o cometimento do delito, nem o tornou mais ou menos reprovável, razão pela qual não há que se falar na aplicação da referida agravante, conforme vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. Sentença de procedência. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Dosimetria. Afastada a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não demonstrada a vinculação entre os fatos e o estado de calamidade pública gerado pela /2022) pandemia de COVID-19. Reduzida proporcionalmente a fração de aumento eleita para agravar a pena em razão da reincidência. Escorreito, na derradeira etapa, o juízo positivo de incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Inviável, por outro lado, a concessão do redutor previsto no artigo 33, §4º, do mesmo Diploma. Regime inicial fechado fixado adequadamente, observada a expressão aritmética da pena e a dupla e específica reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de "sursis". Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1514882-87.2020.8.26.0228; Relator(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro:13/04/2021)

Assim, considerando a reincidência, majoro em 1/6 a pena anteriormente fixada, estabelecendo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Terceira fase da dosimetria.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Anoto que a reincidência específica do réu impede a concessão do privilégio, nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Assim, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial de cumprimento.

Sendo o réu reincidente e em razão do montante de pena, o regime é, necessariamente, o fechado.

A reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a suspensão condicional da pena.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu VINICIUS AUGUSTO DA SILVA, à pena de reclusão, pelo prazo de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a pena de 583 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, em virtude da conduta típica descrita no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas. Tal fato demonstra que a prisão do réu, nos termos do art. 312 do CPP, se faz necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo para impedir a reiteração delitiva. Neste sentido:

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão e todo o necessário para o cumprimento da pena.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA